

1500467-70.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive e observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

2ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500467-70.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500467-70.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2081078/2022 - DEL.POL.GUARARAPES, 23824946 - DEL.POL.GUARARAPES, 253/22/215 - DEL.POL.GUARARAPES, 2081078 - DEL.POL.GUARARAPES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE BRAGA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

PEDRO HENRIQUE BRAGA DA SILVA, conhecido por "Pedrinho", qualificado nos autos (fl. 05), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob os conseqüências da Lei nº 8.702/90, porque, supostamente, no dia 24 de março de 2022, por volta das 6h30, na Rua José Vieira Torres, nº 179, Jardim São Judas Tadeu I, nesta cidade e Comarca de Guararapes-SP, guardava 18 (dezoito) porções, totalizando 2,66g (dois gramas e sessenta e seis centigramas) da droga BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como Cocaína, acondicionados em pinos, tipo eppendorf, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação prévia (fl. 15) e exames químico-toxicológicos (fls. 70/72 e 73/75). O acusado foi notificado pessoalmente (fl. 104) e apresentou defesa preliminar (fls. 111/112).

Ausentes as causas de rejeição do artigo 395 do CPP, a denúncia foi recebida em

20/06/2022 (fls. 113/114).

Não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 113/114).

Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas da acusação e defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Ausentes requerimentos de diligências complementares (artigo 403 do CPP), as partes ofereceram alegações finais escritas (fls. 154/162 e 165/168).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO (artigo 93, inciso IX, da CRFB/88).

Passo à análise da preliminar suscitada pela defesa.

De início, indefiro a instauração de incidente de insanidade mental ou de dependência toxicológica do acusado. O simples fato de alegar ser usuário de drogas não torna obrigatória a realização de tais exames, ainda mais quando se visualiza que ele não apresenta sinais de que à época do crime tivesse sua capacidade de compreensão comprometida, porquanto na audiência revelou plena consciência, entendeu o caráter ilícito de suas ações e dirigiu seu comportamento de acordo com este entendimento. Destarte, rejeito a preliminar aventada.

Não havendo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A ação penal é PROCEDENTE.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 06/08); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação prévia (fl. 15); laudos toxicológicos (fls. 70/72 e 73/75); laudo pericial no aparelho celular apreendido (fls. 101/103); e, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, pela prova oral colhida.

A testemunha Ricardo Cristiano Marques, policial militar, ouvida em sede policial (fl. 03), relatou que, na data dos fatos, por volta das 06h, na companhia do CB PM Emerson, realizaram cumprimento de mandado de busca expedido nos autos do processo 1500099-52.2022.8.26.0218, no imóvel situado na Rua José Vieira Torres, 178, Bairro São Judas, onde reside o acusado Pedro, vulgo Pedrinho. O acusado é extremamente conhecido nos meios policiais como sendo vendedor de drogas e estaria realizando intensa traficância no local. Na residência, não foram atendidos e tiveram que transpassar o muro. O ingresso no imóvel se deu pela abertura da porta pelo acusado. Em busca corporal no acusado, nada foi encontrado. Após revista no imóvel, em um cômodo desocupado, localizaram, dentro de uma caixa de ventilador com vários objetos em desuso, uma pochete cor preta, contendo em seu interior um saco plástico com 17 (dezessete) micro tubos, contendo substância aparentando ser cocaína, além de uma carteira contendo R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Ainda, em outro quarto, sobre a cama de Pedrinho, localizaram um aparelho celular SAMSUNG cor preta com a tela quebrada, além de R\$ 17 (dezessete reais), que estava junto ao celular, totalizando a apreensão de R\$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) em notas diversas. Em outro quarto foi localizado um aparelho celular SAMSUNG J4 de cor rosa em funcionamento, do qual Pedrinho assumiu a propriedade. Questionado sobre as drogas e dinheiro, Pedrinho permaneceu em silêncio.

A testemunha Emerson Cirilo de Sousa Oliveira, policial militar, ouvida em sede policial (fl. 04), ratificou a versão apresentada pelo companheiro de farda.

Em juízo, as testemunhas foram coesas com os respectivos relatos apresentados em sede policial, reiterando o que já haviam declarado.

Registre-se, por oportuno, que em observância à determinação constitucional da razoável duração do processo, bem como do disposto na Resolução nº 105/2010 do CNJ, desnecessária a transcrição dos depoimentos. No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra - cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o escopo somente de reduzir o tempo de

realização do ato, em razão da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. Ao contrário, fortalece a sua segurança. 6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, que, "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". 7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O fato de não terem sido degrevados e transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. 8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada efetivamente a degrevação. 9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação jurisdicional, devendo se harmonizar com este horizonte todos aqueles que nele atuam. (...)" HC 177195 / SP. Também: (...) 1. A mens legis do artigo 405 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/08, consiste em impor como regra o registro dos depoimentos por meios ou recursos de gravação, dentre os quais se declina o audiovisual, afastando-se a necessidade de sua transcrição. RHC 47283 / RS.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais militares se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

O acusado, ouvido em sede policial (fl. 05), reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em juízo (mídias audiovisuais), disse que, na data dos fatos, havia usado droga a noite inteira e, quando os policiais chegaram a sua casa, por volta das seis e meia da manhã, estava acordado, pois tinha passado a noite sem dormir. Contou ter escutado barulho de portas de carro defronte sua casa e que fecha o portão para dormir. Asseverou que faz uso da droga no interior do quarto, sem que alguém veja, nem mesmo sua prima. Ela apenas o observa sob os efeitos das drogas. Relatou ter escutado os policiais empurrando a porta e que sua prima Vitória estava pronta para ir à escola. Mencionou que, ao abrir a porta do quarto, viu sua prima abrindo a porta para os policiais. Narrou que, em seguida, deitou-se na cama. Salientou ainda que foi submetido a busca pessoal, nada de ilícito sendo encontrado. Em relação à droga, explicou ter perdido o ônibus, pois usou entorpecente durante à noite, deixando de ir trabalhar. Confirmou que a pochete tinha 17 pinos e iria levá-la para o serviço, a fim de guardar cigarro e isqueiro. Assumiu a propriedade da pochete e do dinheiro encontrados, informando que o valor era referente à quinzena anterior de trabalho, recebida na quarta-feira. Disse ter recebido R\$710,00 e que pretendia comprar cinco gramas de cocaína para uso, mas como não encontrou no ponto de venda localizado próximo a sua casa, na rua de baixo de sua casa, adquiriu 22 pinos para uso, pagando R\$220,00. Informou ter gastado mais um pouco de dinheiro comprando um maço de cigarros e latinhas de cerveja, sobrando R\$460,00 em sua carteira e R\$12,00, em cima da cama. Perguntado sobre os celulares, respondeu que um deles era seu aparelho antigo, que havia quebrado e estava guardado na gaveta do criado-mudo. Já seu outro aparelho estava no quarto de sua prima, em carregamento. Salientou que não comercializava drogas. Consignou que já foi abordado fora de horário, quando estava em cumprimento de R.A, pois tinha por costume ficar nas esquinas. Informou ser dependente químico desde quando era menor de idade. Não

soube precisar seu consumo diário de drogas, bem como declarou que nunca realizou tratamento no tocante a sua dependência. Asseverou que a droga era para consumo pessoal.

Como percebo, em que pese a negativa do réu quanto ao cometimento do crime, a sua versão encontra-se amplamente dissociada das demais provas coligidas aos autos, em especial dos depoimentos colhidos em juízo.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza e quantidade do entorpecente; (b) a forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) forma com que se deu a prisão do acusado;

Assim sendo, todas essas circunstâncias da ação somadas, demonstram a ocorrência da mercancia ilícita e impede o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória da defesa, não deixando dúvidas que o entorpecente era destinado ao comércio.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237).

Sobre os critérios distintivos entre a tipificação do delito no art. 28 e art. 33 da Lei de Drogas, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive e observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza e quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem

ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9 ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JuPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040).

De acordo com o caso em tela, o acusado tinha em depósito 2,66g (dois gramas e sessenta e seis centigramas) da droga Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína, acondicionadas em pinos, tipo eppendorf, em 17 (dezessete) porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e R\$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) em notas diversas. Conforme depoimentos dos policiais militares, o réu já era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Não bastasse, o acusado deixou de indicar motivação concreta para afastar a idoneidade da versão dos policiais.

De se consignar que a condição de dependente químico não afasta a condenação de delito de tráfico de drogas, vez que é de notório conhecimento que usuários realizem a traficância para sustentar o vício.

Isto posto, inviável a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Cumprе ressaltar que a forma de acondicionamento da droga (distribuída em 17 (dezessete) embalagens plásticas) é um forte indicativo da destinação onerosa ao consumo de terceiros.

Igualmente, incabível a absolvição, vez que a prova é francamente hostil ao acusado.

No mais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de que trata o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto se trata de acusado reincidente.

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

Na primeira etapa, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o acusado ostenta MAUS ANTECEDENTES; agiu com CULPABILIDADE normal à espécie; não há elementos nos autos para aferir a sua PERSONALIDADE ou CONDUTA SOCIAL; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao delito. Não por outra razão, fixo a pena-base em seu patamar mínimo abstratamente previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto aos antecedentes, estes serão analisados na segunda fase da dosimetria, como reincidência, a fim de se evitar o bis in idem.

Na segunda fase da dosimetria, forçoso reconhecer a agravante genérica da reincidência (proc. 1444-15.2017 - fl. 88). Não por outra razão, majoro a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No terceiro estágio inexistem causas de aumento e diminuição da pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda fixada na etapa anterior.

O dia multa é fixado no mínimo legal, ante a inexistência de elementos que permitam aferir a condição econômica do acusado.

A respeito da fixação do regime inicial e a possibilidade de substituição por restritiva de direitos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que fixam o regime inicial fechado obrigatoriamente e que obstem a substituição da pena por restritiva de direitos para o delito de tráfico, pelo que devem ser observados os critérios gerais do Código Penal, conforme aresto que segue:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REEXAME A SER FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.1. Não competia ao Tribunal de Justiça do Acre, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamento novo, não utilizado pelo juízo de primeiro grau, a fim de justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos.2. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em se tratando de tráfico de entorpecente. Precedentes.3. Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo da Vara de Delitos e Tóxicos e Acidentes de Trânsito da Comarca de Rio Branco reexamine dos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional, afastadas as vedações dos arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990." (STF Processo RHC 120416 AC Órgão Julgador Segunda Turma Publicação DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 Julgamento 24 de Junho de 2014 Relator Min. CÁRMEN LÚCIA).

Para início de cumprimento de pena, norteado pelos critérios previstos no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência do acusado, bem como do quantum da pena, a qual também impede a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, condeno PEDRO HENRIQUE BRAGA DA SILVA, conhecido por "Pedrinho", qualificado nos autos (fl. 05), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob os consectários da Lei nº 8.072/90.

Autorizo, desde já, a destruição de entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda em favor da União, dos objetos e valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao Funad, nos termos do artigo 63 e § 1º, da Lei nº 11.343/06.

"Status Libertatis": Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, valendo, a presente deliberação, para os fins do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, porque, conforme folha de antecedentes (fls. 88/89), o réu ostenta antecedentes criminais, evitando-se, ainda, a reiteração da conduta delitiva. Por esta razão, mantenho a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos da decisão proferida nestes autos (fls. 39/40), adotando-as como razão de decidir. Transitada em julgado:

Expeçam-se as guias de execução provisória.

Transitada em julgado:

a) Intime-se o réu para pagamento da multa, expeça-se guia de execução definitiva e forme-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) Oficie-se ao IIRGD;

c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do(s) apenado(s), conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no Enunciado nº 09 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral; Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (artigo 804 do CPP), suspensa a exigibilidade, porquanto lhe concedo o benefício da justiça gratuita. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guararapes, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA